

通信の秘密

海野 敦史

「通信」の根本規範としての通信の秘密

憲法21条の規定

1 項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

2 項 検閲は、これをしてはならない。**通信の秘密は、これを侵してはならない。**

⇒憲法が「通信」について明示する唯一の規定であり、「通信」の根本規範。

問題意識

- ・ 憲法21条 2 項後段は、何を保護しようとしているのか（保護法益は何か）。
- ・ 同条項は誰に対する規範か。公権力のみを拘束するものか。
- ・ 同条項にいう「通信」とは何か。SNS等を用いたコミュニケーションも含まれるのか。
- ・ 同条項にいう「秘密」とは何か。プライバシーと同義か。
- ・ 通信の秘密を「侵してはならない」（侵害の禁止）とはどのようなことを意味するのか。

法律上の通信の秘密に関する主な規定

電気通信事業法 4 条

- 1 項 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
- 2 項 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。

有線電気通信法 9 条

有線電気通信（電気通信事業法第 4 条第 1 項又は第164条第 3 項の通信たるものを除く。）の秘密は、侵してはならない。

電波法 9 条

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信（電気通信事業法第 4 条第 1 項又は第164条第 3 項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の 2 第 2 項及び第 3 項において同じ。）を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

⇒これらの各規定は憲法上の通信の秘密を具体化したにとどまるものなのか？

「通信」の基本的特性

基本的特性

- ① 一定のネットワークその他の通信設備の設置及びその使用を不可欠とする。
- ② 情報の発信者がその着信者を指定するため、通信当事者（発信者・着信者）にとって無関係の第三者に当該情報が知られないこと（秘匿性）に対する利益が生じ得る。
- ③ 情報の送受信のために通信設備を支配・管理する関与者（主に通信管理主体）による一定の助力を必要とし、またそれが予定されている。
- ④ 送受信対象の情報が一時的に通信当事者の一方又は双方の手の届かない（直接的な統御の及ばない）ところにおかれる。
- ⑤ 発信者が送信した情報が最終的に着信者により受信され、又は受信され得る状態におかれることにより、初めて行為として完結する。
- ⑥ 前記①～⑤の帰結として、少なくとも発信者、着信者及び関与者（通信管理主体）からなる「三極関係」を基本とする構造がその成立に不可欠となる。
- ⑦ 前記⑥の帰結として、憲法及びそれに適合的な形で公権力が設営する「通信制度」（「通信」に関する法規範の集合体）に依存しつつ行われる。

憲法21条2項後段の保護法益(Ⅰ)

学説

- ① 「通信」は「表現」の一環であって、基本的に表現の自由（憲法21条1項）の保障を補完するものと解する考え方（**表現の自由補完説**）
- ② 「通信」は「特定者間の通信」であって、それは各人の私的領域に関わるものであるから、プライバシーの保護を主眼とするものと解する考え方（**プライバシー保護主眼説**）
- ③ 前記①及び②の双方の要素をほぼ同等に含意するものと解する考え方（**表現・プライバシー折衷説**）

表現の自由補完説の検討

- ・ 「通信」がもっぱら「表現」の部分概念として捉えられているが、「通信」でやり取りされる情報の中には「表現」とは言えないものも含まれ得る。
- ・ 表出・発信された情報の受領者・受信者の法的地位については、「表現」の下では「能動的な受領を不当に妨害されない」という消極的地位だが、「通信」の下では、受信者が情報を受信し得る状態におかれなければ「通信」は完結しないため、原則として「確実に受信し得る状態におかれる」ための制度的利用環境の確保が前提とされる。

憲法21条2項後段の保護法益(2)

- ・仮にもっぱら表現の自由補完説による場合、「一切の表現の自由」を保障する憲法がなぜ「通信手段を用いた表現」のみを「抽出」してその保護を改めて規定しなければならなかったのか、的確に説明することが困難。

プライバシー保護主眼説の検討

- ・「特定者間の通信」に憲法21条2項後段の適用の射程を限定することは、「通信」にそのような限定を明示的に付していない明文の規定に反することに加え、「特定者間の通信」とそれ以外の通信との分水嶺自体が明確ではない。
- ・「通信」においては通信当事者のプライバシーとの関わりが高い情報から低い情報まで、多種多様な情報が送受信され得るため、「秘密」の概念を「プライバシー」とほぼ同義に解する可能性についても慎重な検討が必要。

表現の自由・プライバシー折衷説の検討

- ・「秘密」が「プライバシー」と同視できない以上、憲法21条2項後段にはプライバシーの保護を超えた法益が含まれているものと捉えることが必要であり、たとえこれに表現の自由の補完という要素を接合させたとしても、不十分。

憲法21条2項後段の保護法益(3)

検討

- ・「通信」の基本的な特性から、国民各人においては、通信事業者等の通信管理主体の助力を得ることなくして、「通信」を完結させることはできない。
- ・よって、「秘密」についても、通信管理主体の意思により、又は公権力に対する当該主体の協力（情報提供）により、侵されるリスクを内包する。
- ・一般に、通信当事者は、かかるリスクを承知のうえで、統治主体としての公権力が「秘密」たる情報にみだりに接触しないこと及び通信管理主体が適切に当該情報を取り扱うことを信用しつつ、一定の契約等を通じて通信管理主体に情報の伝送等を託す。
- ・上記所為は、一次的には通信当事者各人の選択という主観的要素に基づくが、個々の通信に際して公権力や通信管理主体による「通信の秘密」を構成する情報の不当な探索が行われないことに対して、利用者全体（通常人を念頭においた社会）が普遍的に抱いていると認められる「客観的な期待」を土台として成立している。
- ・上記「客観的な期待」の内実を国民各人の視座に置き換えると、それは、「通信」を利用する**国民各人が公権力や通信管理主体に対して有する「信頼」**にほぼ等しい。

憲法21条2項後段の保護法益(4)

- ・国民各人の「信頼」は、一次的には、送受信対象となる情報及び「通信」の構成要素となる情報について、その具体的な内容やプライバシーとの関わりの度合いに関係なく包括的に適正な取扱いを行うことに対するもの。
- ・「秘密」とはかかる「信頼」に基づいて発現し、その不可侵とは、当該「信頼」に反すると認められる行為の禁止をその基軸としていると考えられる。
- ・伝送行為等を託される通信管理主体においても、この「信頼」に背くことのないよう、「秘密」たる情報の秘匿性を維持しながら、適切な取扱いを行う。
- ・よって、「秘密」の保護法益とは、国民各人の「通信」の利用における客観的かつ総合的な「信頼」にほかならず、その侵害が問題となるのは、かかる「信頼」の向かい先となる公権力及び通信管理主体との関係においてのみ（一般私人との関係は射程外）。
- ・一般私人をも「法律上の秘密」の侵害の射程に含めている立法措置については、「通信」の主要な制度的利用環境の確保の観点からの立法政策の所為として理解。
- ・国民の誰もが上記「信頼」の下で安全に安心して「通信」を利用できる制度的環境を適切に確保することが、通信の秘密を保護する基幹的な意義。

⇒「秘密」の保護の前提として、「**通信の自由**」が保護されると解される。

憲法21条2項後段の保護法益(5)

- ・ 憲法21条2項後段が「通信の自由」を保護し、「通信」の健全な制度的利用環境の確保を指向していると解される以上、「通信におけるプライバシー」の保護はその一要素。
- ・ 「通信」が安定的に成立するためには、通信当事者のプライバシーの確保のみでは足りず、ネットワークの設営とその相互接続、ネットワーク上におけるセキュリティ、「基本的な通信役務」の適切な提供といった多様な要素の総合的な確保が不可欠。
- ・ 実際、電気通信事業法等の「通信」の実定法上は、プライバシー的観点からの「秘密」の保護に関する条項よりも、ネットワーク同士の相互接続、通信設備の維持・管理、全国あまねく基本的な通信役務を提供することの確保等に関する規律の割合が高い。
- ・ 憲法規範としての秘密不可侵については、「秘密」という象徴的な用語を通じて、これらの各要素を包括するものとして理解することが合理的。
- ・ したがって、通信当事者のプライバシーの保護は「秘密」の代表的かつ重要な一内実（表徴）であると言えるが、「プライバシー＝秘密」ではない。「秘密」とは極めて多義的な概念であり、プライバシーはその一要素にすぎないと考えられる。

憲法21条2項後段にいう「通信」の射程(Ⅰ)

学説

- ・伝統的には、「通信」を内的な（特定者間の）コミュニケーション過程と捉える考え方が有力。
- ・その延長線上には、特定者間に限定されない「表現」を「通信」の上位概念と捉える考え方も。
- ・かかる理解の下では、内容がオープンな「公然性を有する通信」は、憲法上の「通信」の射程から外れる（通信の秘密の保護領域を縮減させる試み：**公然性通信除外説**）。

検討

- ・「通信」は基本的に通信当事者の間におけるコミュニケーションの完結のために一定の関与を行う者（通信管理主体）の適切な助力によって初めて成立する。
- ・通信管理主体の助力はネットワークその他の通信設備を介して行われ、その設備は相互に接続されることによりその効用を最大化し得る。
- ・それゆえ、「通信」は、一定の通信制度の下で成立する行為であり、自然状態で各人の独力により実現し得る「表現」とは異質の特徴を有している。

憲法21条2項後段にいう「通信」の射程(2)

- ・確かに、公然性通信除外説によれば、内的なコミュニケーションのイメージが強かった「通信」の領域に登場した「異物」としての公然性を有する通信について、「秘密」の保護と切り離すことが可能となる。
 - ・しかし、公然性を有する通信も「通信」の一形態であり、憲法21条2項後段の明文の規定はこれをその保護対象から排除していない。
- ※なお、電気通信事業法において、「電気通信」は「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を**送り、伝え、又は受ける**こと」と定義されており（同法2条1号）、送信・伝送・受信の対象となる符号等が公然性を有するか否かは何ら問われていない。
- ・憲法21条2項後段の規定が「通信の自由」を保護する中で、公然性を有する通信が「通信」の射程から外れる場合には、「公然性を有する通信の自由」が保護されないという不合理なことになり得る。
 - ・これは、今日の国民生活に組み込まれたインターネット経由の通信のうち一定のオープンなものに対する憲法的保護を低減させ、その制度的利用環境を（他の態様の通信と比べて）危うくする結果、各人の人格の発展をも阻害し得る。

憲法21条2項後段にいう「通信」の射程(3)

- ・公然性を有する通信においては、内容情報としてのメッセージはオープンなものであるかもしれないが、通信の日時、場所等のメタデータ（構成要素情報）については必ずしもその限りではない。
- ・よって、公然性を有する通信の内容情報がオープンなものであるということと、当該通信の「秘密」が憲法上保護されないということとは、当然に連動するものではない。
- ・「秘密」の保護に対する要請は、個々の情報が実際に有する秘匿性の度合いとは関係なく包括的に「秘密」の保護の網をかけている。公然性を有する通信においても「秘密」たる情報は発現し得るのであって、当該通信に対してもその要請は及ぶと解される。
- ・公然性を有する通信といえども、少なくとも技術的には、通信管理主体の関与を伴いつつ「一対一の通信」が集積されて実現されるため、他の態様の通信と規範的に区別される合理性が乏しい。
- ・同時に、発信当時は公開を予定していた通信の内容情報がその流通過程等で事後的に秘匿性を帯びることもあり得るため、公然性を有する通信とそれ以外の通信との分水嶺自体が不分明。
- ・公然性を有する通信を含め、今日の「通信」は国民生活のあらゆる局面に組み込まれ、個人の尊厳を支える重要な基盤の一つとなっている中、憲法はその制度的利用環境を保護¹²

憲法21条2項後段にいう「秘密」の意義

- ・ 前述のとおり、「秘密」は多義的。
- ・ 狭義においては、国民各人の「通信」の利用における公権力及び通信管理主体に対する「信頼」を保護するもの。
- ・ その「信頼」は、通信管理主体による個々の通信の取扱中のみならず、その完了後にも及ぶと考えられるため、「秘密」は個々の通信の完了と同時に消滅するものではない。
- ・ 通信管理主体は、かかる「信頼」に応じることが予定された第三者として、個々の通信に関する各種の「秘密」たる情報を正当に知り得る立場におかれており、その利用者たる国民各人にとっての脅威となる主体ないし「情報権力」としての「顔」も有している。
- ・ 広義においては、「通信」の健全な制度的利用環境（通信基盤を含む）を保護するもの。
- ・ すなわち、国民各人が安全に安心して特段の支障なく通信役務を利用でき、その中で狭義の「秘密」を構成する情報がみだりに外部に漏えい等することなくネットワーク上を流通するための基盤（通信基盤）をも含意するもの。
- ・ そのような制度的利用環境を立法を通じて形成していくことは、公権力の役割。

憲法21条2項後段の規定の名宛人(1)

学説

- ・ 憲法規範は、一次的には公権力をその名宛人とすることから、私人たる通信管理主体が「秘密」の保護の要請に直接拘束されるか否かは重要な論点。
- ・ 伝統的な学説は、公権力に加えて、通信管理主体も当該要請に直接拘束されると解釈。
- ・ その背景には、かつては通信役務が国営公社により提供されており、通信管理主体を公権力と同視することが容易であったという事情も。
- ・ 近年の一部の学説は、公権力のみが直接拘束されると解釈（**秘密保護要請公権力限定説**）。

検討

- ・ 公権力が「秘密」たる情報に接触しなくとも、通信管理主体がそれをみだりに開示したり、ネットワーク上の物理的な障害、不具合等で当該情報が漏えいしたりするような事態が頻発すれば、国民各人においては安心して「通信」を行うことが困難に。
- ・ 仮にその「秘密」が公権力及び通信管理主体の双方との関係上保護されなければ、その利用者においては、公権力が通信管理主体の助力を得つつ自らの知らないところで「秘密」たる情報をみだりに探索する脅威から解放されない。

憲法21条2項後段の規定の名宛人(2)

- ・ 伝統的な学説が通信管理主体も直接拘束されると解釈したのも、通信管理主体が個々の「秘密」たる情報を直接取り扱っていたという要素からであったと考えられ、それが公権力を行使する行政主体であるか否かに焦点が当てられていたわけではない。
- ・ 基本的な通信役務の内容自体に関しては、通信事業の民営化の前後で重大な変化が生じることとなったわけではないにもかかわらず、その提供者の属性が「官」から「民」に移行した途端に憲法上の要請から「解放」されると解することは、論理的な飛躍を伴うもの。
- ・ 通信事業の運営形態の変化にかかわらず、「秘密」たる情報を直接取り扱いつつ他人間の通信の完結に寄与する者を公権力に準じた通信管理主体として捉え、これを憲法21条2項後段の名宛人として引き続き位置づけることが合理的。
- ・ もっとも、公権力が通信管理主体に対して「秘密」を保護させる立法義務を負うにすぎず、通信管理主体が憲法21条2項後段に直接拘束されるわけではないと解する考え方も成立する余地がないわけではない。
- ・ しかし、立法の内容については、それが（憲法上の要請をくまなくカバーするほどに）十分であるという保証はなく、通信管理主体が憲法21条2項後段の名宛人とならないことを裏づけるものとはならない。

※ 「通信」を取り巻く技術革新のスピードが急速である中で、それに立法が適時適切にくまなく対応することは本質的に困難。それゆえ、憲法が通信管理主体による「秘密」の保護をもっぱら立法に委ねているとは解しがたい。

憲法21条2項後段の規定の名宛人(3)

- ・ 以上のように考えれば、通信管理主体は、個々の通信の取扱いの局面では、憲法21条2項後段のみならず、憲法14条1項の平等原則にも拘束されると解される。
- ・ 仮に通信管理主体が憲法規範に何ら拘束されず、法律上の規定にのみ拘束されるとすれば、自らのネットワークを表現媒体とする表現の自由や設備に対する財産権等の行使を通じて、特定の流通情報に対する差別的取扱い、「秘密」たる情報の営利目的での利用、個々の通信役務の提供拒否等の恣意的な取扱いを任意に行う余地が生じ得る。

⇒「通信」の利用者は憲法規範の次元において極めて不安定な環境におかれ得る（ただし、これらの恣意的な取扱いは法律上基本的に禁止されている）。
- ・ 通信管理主体を一般私人と同列に捉える限り、任意の恣意的な取扱いがなぜ法律に基づき広範に制約されなければならないのか、的確な説明を行うことは困難に。
- ・ 仮に通信管理主体において憲法上「秘密」の保護が義務づけられないのであれば、法律上の行為規範が通信管理主体の表現の自由その他の基本権の行使を広範に制約する中で、その立法の合憲性が十分に立証されなければならないが、当該立証は学説上不十分。
- ・ よって、通信管理主体も、個々の通信の取扱い上は、いわば「準公権力」として、公権力とともに、憲法規範に拘束されると解される。

通信管理主体の類型

伝送系通信管理主体

- ・ 一般的な通信事業者等、伝送行為に従事しつつ他人間の通信を媒介する者。
- ・ 媒介とは、他人の依頼を受けて、情報をその内容を変更することなく伝送・交換し、隔地者間の通信を仲立ちしてそれを完成させることを指す。
- ・ 「秘密」を構成する情報には基本的にみだりに接触しないことが原則となる。

非伝送系通信管理主体

- ・ SNSの管理者等、伝送行為には従事せずに他人間の通信の「実質的な媒介」に携わる者。
- ・ 実質的な媒介とは、SNS等の双方向型プラットフォームを介して行われる他人間の情報のやり取りについて、当該プラットフォームの管理・運営に対する権限を通じて、伝送行為を伴うことなくその完結に寄与することを指す。
- ・ 上記権限に根ざす「編集権」から、流通情報の加工、修正、削除等に従事することが予定される。

通信の秘密の「侵害」の射程（Ⅰ）

学説

- ・ 伝統的には、公権力又は通信管理主体による「秘密」たる情報の**積極的知得**、**漏えい**。

※公権力には積極的知得、通信管理主体には漏えいが、それぞれ「侵害」に該当する行為と解する学説も。
- ・ 知得した情報を通信当事者の意に反して利用する「**窃用**」も「侵害」の射程に含める学説も。

検討

- ・ 公然性を有する通信も憲法上の「通信」であるが、公開を目的とするプラットフォーム等を介して誰もが容易にアクセス可能と認められる情報のやり取りに関する通信（公開予定通信）の内容については、その積極的知得や漏えい等が「侵害」に該当する余地は乏しい。
- ・ 「侵害」の主体は、①公権力、②伝送系通信管理主体、③非伝送系通信管理主体。
- ・ 非伝送系通信管理主体が有するプラットフォーム上の流通情報の「編集権」に照らせば、その積極的知得等の行為の「侵害」への該当性は、伝送系通信管理主体の場合よりも緩やかに捉えることが合理的。

通信の秘密の「侵害」の射程（２）

- ・「秘密」の保護法益に照らせば、通信当事者が通信管理主体に対して有している「信頼」に背馳する行為と認められるか否かが「侵害」への該当性を判断する決め手。
- ・例えば、非伝送系通信管理主体による役務提供の機能上予定されている流通情報の加工、削除等の行為は、「信頼」に背馳するものとは認めがたいが、仮に伝送系通信管理主体が無断で同様の行為を行えば「信頼」に背馳。
- ・行為の類型としては「侵害」に該当する可能性のあるものであっても、以下の行為については、その実施態様が正当な目的に相応する形で比例原則等を充足する限り、「侵害」に該当しないと整理すべきであると考えられる。
 - ① 公権力が「公共の福祉」を確保するために行うものと認められる行為
 - ② 通信管理主体が「通信」の主要な制度的利用環境ないし通信基盤の健全性の確保のために必要となる範囲で行うものと認められる行為
 - ③ 通信当事者の明示的かつ個別的で有効な同意（任意の承諾）があらかじめ得られている行為

※有効な同意は、発信者及び着信者の双方により明示的かつ個別的に行われる同意であることが原則。ただし、個々の通信の構成要素となる情報のうち、もっぱら一方の通信当事者のみに関わると認められる情報については、当該当事者の同意のみで足りる。

通信の自由の意義（Ⅰ）

学説

- ・「秘密」の保護の論理的な前提として、「通信の自由」が保障されると解されている。
- ・「通信の自由」は「表現の自由」に含まれるから、「通信の自由」という基本権をあえて観念する必要はないと説く学説もある。

検討

- ・「通信」は「表現」の部分概念ではなく、やり取りの対象となる情報には非表現物（表現物とは言えないもの）も含まれるため、「通信の自由」は固有の基本権。
- ・今日の「通信」は、「個人の尊厳」（憲法13条）を支え、「健康で文化的な最低限度の生活」（憲法25条1項）を営むために不可欠のツール。
- ・「表現」とは異なり、「通信」は独力かつ自然状態で実現可能なものではない。立法を通じた一定の通信制度に基づく利用環境が予定されている。

通信の自由の意義（2）

通信の自由の要請の内実

- ① 通信手段を用いた表現の自由の保障
- ② 通信手段を用いた表現以外の情報発信の自由の保障
- ③ 通信手段を用いた情報着信の自由の保障
- ④ 「基本的な通信役務」の（通信管理主体による）適切な提供の確保
- ⑤ 通信管理主体による通信設備の適切な管理の確保
- ⑥ 通信管理主体の支配・管理する複数のネットワーク同士の相互接続の確保
- ⑦ 通信役務の提供におけるネットワーク上の最低限の安全性及び信頼性（セキュリティ）の確保
- ⑧ ネットワーク空間における「情報の自由な流通」の原則的な実現の確保
⇒憲法規範に照らして問題となる情報が排除される措置の実施努力を含む
- ⑨ 憲法適合的な通信制度の適切な設営